

1506577-46.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... de qualquer maneira deve ser condenado pelo tráfico de drogas (artigo 33, da Lei 11.343/06), já que tal atividade, de "olheiro", é diretamente ligada ao hediondo comércio, atuando a pessoa nesse sentido como coautor do delito de tráfico de drogas, porque participando da efetiva execução dele, não se confundindo com a conduta prevista no artigo 37 da Lei 11.343/06, de mero ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506577-46.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506577-46.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE ALVES ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

LUIZ HENRIQUE ALVES ARAÚJO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 18 de março de 2022, por volta das 16h30, durante estado de calamidade pública (Decreto Estadual nº 64.879/2020 - COVID-19), na Rua das Jangadas, nº 90, Viela Aristóteles, Vila Andrade, nesta capital, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de traficância e consumo de terceiros, 156 (cento e cinquenta e seis) tijolos de tetrahydrocannabinol, substância conhecida como maconha, pesando 114,13 kg (cento e quatorze quilogramas e cento e trinta gramas); 25 (vinte e cinco) porções de tetrahydrocannabinol, substância conhecida como maconha, pesando 557,2 g (quinhentos e cinquenta e sete gramas e dois decigramas); 01 (uma) porção de cocaína, pesando 513,2 g (quinhentos e treze gramas e dois decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de três balanças, um martelo, duas facas, dez fitas adesivas, um rolo de filme plástico, quatro aparelhos

celulares, um molho de chaves e R\$ 328,00 (trezentos e vinte e oito reais) em espécie.

Notificado, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, o acusado apresentou Defesa Prévia, subscrita por Defensora constituída nos autos (pág. 116/124).

Recebida a denúncia (págs. 134/137), durante a instrução criminal, foram inquiridas as testemunhas arroladas, interrogando-se ao final o réu. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça insistiu na condenação, nos exatos termos da denúncia.

A Dra. Defensora, por sua vez, pugnou, preliminarmente, pela declaração de nulidade das provas obtidas, porque derivadas de revista pessoal e busca domiciliar desprovidas de fundada suspeita/mandado de busca e apreensão. No mérito, requereu a absolvição e sustentou, em síntese, atipicidade da conduta e precariedade probatória. Alternativamente, requereu a desclassificação do crime denunciado para a figura típica prevista no artigo 37 ou artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requereu: (I) fixação da pena base no mínimo legal; (II) aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo; (III) afastamento da agravante da calamidade pública; (IV) fixação de regime inicial aberto; (V) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (VI) aplicação do benefício previsto no artigo 77 do Código Penal; e, por fim, (VII) seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
D E C I D O.

De início, afasto as preliminares de nulidade levantadas pela Dra. Defensora.

Por primeiro, cumpre destacar que a abordagem policial foi lícita e plenamente justificada no caso concreto. Conforme se verificou, os milicianos patrulhavam pela comunidade do Paraísoópolis, adentraram uma viela e se depararam com o acusado, que, ao notar a presença da guarnição policial dispensou uma sacola contendo tijolos de maconha: “Ele estava carregando a sacola no braço, né. A suspeita veio da reação dele, na hora que ele viu a equipe, ele tava andando, aí parou, ficou olhando pra gente e dispensou a sacola, jogou no chão. Sim (viu o réu jogando a sacola), tanto que ele foi questionado”, o que motivou a abordagem. Portanto, tais circunstâncias indicam a existência de fundada suspeita, a justificar a realização da busca pessoal, nos termos dos artigos 240, §2º, e 244, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido: “Tráfico de drogas – Recurso defensivo –Nulidade da busca pessoal – Inocorrência – Indivíduo em atitude suspeita que, ao perceber a presença da equipe policial dispensou uma sacola e evadiu-se – Sentença condenatória – (...) Recurso Improvido”. (TJ-SP – Apelação Criminal nº 0022225-37.2020.8.26.0576, Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz, 4ª Câmara de Direito Criminal, DJe em: 08/07/2022).

E ao contrário do que tenta fazer crer a Dra. Defensora, a localização dos entorpecentes que o acusado trazia consigo sequer derivou de revista pessoal, já que, como dito, ele dispensou a sacola contendo tijolos de maconha na via pública, o que fez logo que avistou os policiais militares.

A reforçar a existência de fundada suspeita, cumpre ressaltar que referidos milicianos já estavam cientes da ocorrência do tráfico ilícito de entorpecentes no local dos fatos, uma vez que um casal havia sido detido há poucos minutos nas proximidades, em posse de tijolos de maconha, e fornecido informações acerca do endereço, das características físicas e das vestimentas do fornecedor das drogas – que coincidiam com as do acusado.

Com relação à aventada nulidade das provas obtidas por força de invasão domiciliar não autorizada, impende ressaltar que os entorpecentes eram armazenados em um imóvel inabitado, que não funcionava como residência e, portanto, não se enquadra no conceito de domicílio, não estando abarcado pela garantia constitucional da inviolabilidade. Logo, não há que se falar em busca domiciliar.

Nesse sentido: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE ARMAZENAMENTO DE DROGAS E DE ARMAS. BUSCA E APREENSÃO EM APARTAMENTO NÃO HABITADO (...). PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONCEDIDA À RESIDÊNCIA/DOMICÍLIO QUE SOMENTE ABRANGE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS DESTINADOS À HABITAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA, E O LOCAL DE TRABALHO. (...). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) Sem desconsiderar a proteção constitucional de que goza a propriedade privada, ainda que desabitada, não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que tal imóvel é utilizado para a prática de crime permanente (armazenamento de drogas e armas), o que afastaria a proteção constitucional concedida à residência/domicílio.” (STJ – HC nº 588.445/SC, Relator (a): Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 – Quinta Turma, DJe em: 25/08/2020). “Tráfico de drogas e porte de arma de fogo com numeração suprimida e de munições – Invasão de domicílio não configurada – Imóvel não era domicílio de ninguém – Crime único mantido – Autoria demonstrada Conjunto probatório satisfatório” (TJ-SP – Apelação Criminal nº 1520819-78.2020.8.26.0228, Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira, 12ª Câmara de Direito Criminal, DJe em: 16/05/2022).

A corroborar essa convicção, o próprio acusado, qualificado no distrito policial, declarou residir à “R. Herbert Spencer, 392, Vila Andrade, CEP 05663-010, S.PAULO - SP” (págs. 11/12), endereço diverso do local dos fatos.

O conjunto probatório produzido bem demonstrou que o local funcionava como verdadeiro depósito de drogas e petrechos destinados a embalagem, fracionamento e pesagem das substâncias ilícitas, de forma que nem de longe pode ser considerado domicílio.

Ainda que assim não o fosse, no que diz respeito à busca domiciliar desprovida de determinação judicial, é certo que as hipóteses permissivas possuem caráter de excepcionalidade absoluta e taxativa. O texto constitucional preceitua que: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988).

E como já dito, os policiais militares, sempre que ouvidos, detalharam a dinâmica da diligência que realizaram e revelaram a fundada suspeita que justificou terem ingressado no imóvel referido na denúncia, uma vez que abordaram o acusado na rua – logo após o terem visto dispensando uma sacola contendo tijolos de maconha –, e, quando questionado, declarou que os entorpecentes eram oriundos de “uma casa que continha droga, dentro da viela”.

Ato contínuo, o próprio acusado os levou até o imóvel em questão e lhes franqueou o ingresso, abrindo a porta com um molho de chaves que trazia consigo, oportunidade em que localizaram os entorpecentes referidos na denúncia – mais de cem quilos de maconha e uma grande quantidade de cocaína –, juntamente com inúmeros petrechos utilizados nesse comércio espúrio.

Logo, não há que se falar em violação de domicílio, uma vez que o próprio acusado autorizou o ingresso dos policiais militares no imóvel, como muito bem demonstrou a prova produzida nos autos.

Nesse sentido: “A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência.” (STF – AgRg no HC nº 191508/ES, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe em: 25/11/2020).

Ainda: “O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto a entrada na casa foi franqueada pelo ora agravante, ao passo que o referido Tema trata de entrada forçada no domicílio sem mandado judicial. (...) Agravo regimental desprovido.” (STF – ARE 1312140 AgR/SP, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe em: 14/06/2021).

Não fosse assim, é certo que o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, máxime na modalidade de manter em depósito, é crime permanente, cuja situação flagrancial se perpetua no tempo, a permitir a entrada dos agentes da lei no imóvel, não havendo, assim, afronta à Constituição Federal, à legislação ordinária (artigo 240 do CPP), ou ao Tema 280 do E. Supremo Tribunal Federal, de forma que não há nulidade a ser declarada e muito menos prova ilícita.

Nesse sentido: “PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA LÍCITA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES VERIFICADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/R0, decidiu que o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. 2. Hipótese em que os policiais militares receberam denúncia anônima da traficância pelo réu e, ao o abordaram em via pública, foi apreendido com 2 tijolos de maconha. Após a busca pessoal, recolheram na sua casa mais 24 tijolos de maconha, com peso total de 22.603,52g, 2.296 invólucros de cocaína (1.468,75g), 151,93g de crack e 178 frascos de lança perfume. Tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência, consoante pacífico entendimento desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg no HC 738310/SP, Relator(a): Min. Ribeiro Dantas, T5 – Quinta Turma, DJe em: 10/08/2022).

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (STF – Plenário – RE 603616/R0, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 04 e 05/11/2015) (Repercussão Geral – Tema 280).

E ainda que assim não fosse, eventual irregularidade havida em sede de inquérito policial não macula a instrução penal, realizada em contraditório pleno.

Logo, não há falar em nulidade na fase investigatória, pois nessa fase não se vislumbra um processo, mas, sim, um procedimento de caráter preliminar e informativo, cujos vícios são considerados meras irregularidades, que não afetam a ulterior ação penal que nele porventura se basear.

Nesse sentido: “O inquérito policial é peça meramente informativa, na qual não imperam os princípios do contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual eventuais vícios ou irregularidades ocorridos no seu curso não têm o condão de macular a ação penal” (STJ - HC 222725/MG, Relator(a): Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe em: 12/12/2016).

“Eventuais nulidades ocorridas durante a etapa das investigações, meramente

informativa, não têm o condão de contaminar a ação penal posteriormente instaurada". (STJ - AgRg no HC nº 680717/AP, Relator(a): Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe em: 25/03/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, FLAGRANTE FORJADO E ILEGAL OU REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS - IMPOSSIBILIDADE - FLAGRANTES REGULARES, A INICIAL NÃO É INEPTA E EVENTUAL MÁCULA DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO VICIA A AÇÃO PENAL - AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS - NADA A RETIRAR CREDIBILIDADE DOS RELATOS POLICIAIS QUE REALIZARAM AS DILIGÊNCIAS BEM SUCEDIDAS - DENÚNCIA ANÔNIMA CONFIRMADA - LOCAL USADO COMO PONTO DE EMBALAGEM E VENDA DE DROGAS - CAPTAÇÃO FORTUITA DE COMUNICAÇÃO COM OUTRO TRAFICANTE, O QUE PERMITIU NOVO FLAGRANTE - CONDENAÇÕES BEM LANÇADAS - PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO - O TRÁFICO EM PONTO TURÍSTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, A REINCIDÊNCIA DE KAIQUE E JULIANE, A QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO ("CRACK") JUSTIFICAM AS REPRIMENDAS IMPOSTAS - REGIME ADEQUADO - RECURSOS DESPROVIDOS." (Relator (a): Euvaldo Chaib; Comarca: Olímpia; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 14/02/2017; Data de registro: 16/02/2017).

"Habeas corpus" visando desconstituição da prisão preventiva. 1. Circunstâncias a indicar que a custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública. 2. Não configuração, observados os limites do "habeas corpus", de irregularidades no inquérito policial. De toda sorte, como se sabe, eventual vício no inquérito policial não contamina a ação penal. Ordem denegada". (Relator (a): Laerte Marrone; Comarca: Panorama; Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 26/01/2017; Data de registro: 30/01/2017).

Por todo o exposto, afasto as preliminares levantadas.

No mérito, é procedente a presente ação penal.

A materialidade do delito veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 05 e seguintes); boletim de ocorrência (págs. 14/18); auto de exibição e apreensão (págs. 19/20); laudo de constatação (págs. 32/35); laudo de exame químico-toxicológico (págs. 107/109), que apontou para a presença de tetrahydrocannabinol e cocaína nas substâncias analisadas; bem como pela prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda no calor dos fatos, perante a D. Autoridade Policial e na presença de sua advogada, o acusado negou a imputação, declarando que: "(...) estava saindo da viela quando foi abordado pelos policiais militares. Que quando foi abordado estava portando um "baseado". Que os policiais militares disseram que sabiam quem ele era, dizendo que o indiciado tinha o vulgo "menor", mas afirma que seu vulgo é "minica". Que os policiais o colocaram no canto e entraram na viela." (págs. 11/12).

Em Juízo, já sob o crivo do contraditório, da mesma forma, negou a responsabilidade por todo o material ilícito apreendido, mas apresentou outros esclarecimentos, dizendo agora que seria o "olheiro" do tráfico, ou seja, tinha a função de alertar os traficantes sobre o eventual ingresso de policiais militares em uma viela.

Entretanto, negou que estivesse portando uma sacola contendo tijolos de maconha ou as chaves do imóvel que funcionava como depósito de entorpecentes, justificando que sequer tinha conhecimento das drogas que lá eram armazenadas.

Em suma, narrou que: "Tenho a dizer que, realmente, era eu sim, eu era o olheiro dessa casa, infelizmente estava precisando, não fazia nem um mês que eu tava trabalhando ali, mas foi onde tudo aconteceu, surgiu essa oportunidade pra mim, em cima de muita precisão, passando por necessidades, infelizmente, eu agarrei essa

oportunidade, e é isso que eu tenho a falar. Eu era só o olheiro da casa, não sou dono de nada, e eu também não levei eles até lá não. Eles pegaram a chave no meu bolso, chegou lá me chamando de menor, chegou falando que tava procurando um menor, que tinham pegado a droga com um menino do Gol Branco que falou que era eu, foi naonde tinha um monte de policiais lá na viela, acharam essa casa, depois me levaram lá pra dentro e falaram pra mim assumir tudo, que era eu, que eu era o dono de tudo aquilo, mas não sou o dono de nada não. Não (não tinha chave no bolso). Eu era olheiro da rua, eu não cuidava da casa. Olheiro é quando você vê a polícia e tem que avisar pros 'menino', pro dono da casa. Fui pego de surpresa, não deu tempo (de avisar os traficantes sobre a presença dos policiais). Não fez nem um mês, foi muito rápido. Eu telefonava (para avisar os traficantes sobre a chegada da polícia). Tinha duas gramas de maconha no meu bolso (no momento da abordagem), foi com isso que ele cismou, e com o dinheiro. Não tinha sacola nenhuma não. Eu tava parado. Eles abordaram porque já veio atrás dessa casa, pelo que eles falaram eles tavam atrás de uma casa, que tinha drogas, que era um menor, por causa do meu tamanho, da minha fisionomia, eles pensou que era eu e, realmente, eu tava de olheiro. Era uns 500 metros (sobre a distância do local da casa e do local da abordagem), era menos, eu não sei distinguir, eu tava longe da casa, a casa era bem longe, lá na viela, lá no fundo. No local da abordagem eu não tinha visão da casa. Se eles fossem entrar na viela eu avisava, minha função era aquela. Chave eu não tinha não. Não aponteí nada pra eles, eles falou que foi um 'cliente' que apontou, que eu nem sei quem é também. Eu ganhava 300 reais por semana. Eu tinha 300 reais no bolso. Era do que eu tinha ganhado. Eu tinha recebido na quinta-feira. Foi só um só que me contratou. Não (não entrava na casa), eu sabia que tinha que cuidar dela e que quando a polícia entrasse na viela era pra avisar, mas eles não me deixaram entrar lá dentro não. Depois que eles (policiais) entraram nessa casa foi que me levaram pra dentro da viela e começaram a me interrogar. Teve um grandão, que não lembro o nome dele, que me deu um tapa na cara, falando pra eu falar de quem era a droga, e eu disse que eu não sabia, e ele falou que eu que era o menor. Diz eles que entraram com a chave, mas eu não vi, eu tava do lado de fora, depois que eles abriram a casa que me levaram lá dentro. Só vi essa chave na delegacia. Nem eu sabia onde era a casa, eles falaram que era no final da viela. Eu tinha que guardar a viela, porque a viela era sem saída, mas eles nem me mostravam a casa. Moram algumas pessoas naquela viela, tem bastantes casas, é uma viela sem saída. Não entra carro na viela. Ela é muito estreita, acho que não entra carro não, nunca vi entrando carro, só moto. Não sei (onde era o ponto de venda), eles não faziam negociação perto de mim, minha função era apenas olhar. Não (não conhecia os policiais), nunca nem tinha visto eles.".

Referida exculpatória, além de previsível e bem pouco consistente, restou isolada nos autos, desacompanhada de qualquer demonstração probatória de veracidade, sendo refutada cabalmente pela prova adversa – notadamente pelo firme relato das testemunhas inquiridas, sem olvidar das incriminadoras circunstâncias da prisão em flagrante que realizaram –, o que comprometeu sobremaneira o réu.

Os policiais militares responsáveis pela diligência, nas oportunidades em que foram inquiridos, apresentaram esclarecimentos harmônicos e consistentes a respeito dos fatos.

Robson Noguchi de Lima relatou que: "Sim (recorda-se da ocorrência). Sim (recorda-se do acusado). Estávamos em patrulhamento pelo Paraísoópolis com vistas a motocicletas que praticavam roubos na região, momento em que eu vi o indivíduo saindo da viela com uma sacola contendo dois tijolos de maconha. Foi abordado, na hora que ele avistou a equipe, ele jogou a sacola do lado de um carro, aí eu questioneí ele onde estava a sacola, ele falou que não sabia e tal, aí eu achei do lado do carro. No bolso dele, havia um molho de chaves né, a gente questionou ele e ele falou que era de uma casa que continha droga, dentro da viela. Aí nesse momento ele levou a gente até a residência, a gente abriu a casa e tinha uma grande quantidade de maconha, vários tijolos né, maconha e apetrechos para tráfico. Ele

estava carregando a sacola no braço, né. A suspeita veio da reação dele, na hora que ele viu a equipe, ele tava andando, aí parou, ficou olhando pra gente e dispensou a sacola, jogou no chão. Sim (viu o réu jogando a sacola), tanto que ele foi questionado, (...) ele jogou do lado de um carro que tava estacionado na via. (a chave do imóvel) estava no bolso dele. Sim (a casa era próxima ao local da abordagem), ficava a cerca de 300-500 metros. Lá havia uma cama, não me recordo se tinha banco, mas havia um raque. Basicamente era para embalar maconha, tinha uma balança grande. Não me recordo se tinha outra droga, era apenas a maconha, não me recordo se tinha um pouquinho de cocaína... não me recordo. Havia maconha na sacola, três tijolos grandes. Aí na casa foram encontrados cerca de 170 tijolos. O dinheiro, se não me falha a memória, estava no bolso dele, uma pequena quantia. Lá tinha plástico filme, marreta, faca, coisas características. Não (não apuraram se alguém residia naquela casa), a princípio era só para a prática de tráfico. Havia somente um banheiro, era um cômodo com um banheiro só. Ele falou que a droga realmente era dele, inclusive ele havia distribuído para um casal do interior com um Gol Branco alguns tijolos de maconha, que a equipe de força tática havia abordado. Depois ele comentou que tava na prática realmente. Ele comentou (comentou há quanto tempo praticava o tráfico ilícito de entorpecentes), mas não me recordo. Sim (se o colega participou da diligência desde o início), a gente estava junto, na mesma equipe. O barraco estava fechado. Entrei através do molho de chaves, a gente questionou ele e ele falou que ia levar a equipe até lá. Foi a equipe da força tática (que abriu a porta), tava com a chave na mão e ele tava junto. Ele guiou a equipe até lá e a equipe abriu a porta através da chave. Se não me engano, (a cocaína) estava perto da maconha, ao lado da cama. Estava tudo distribuído pela casa. A equipe de força tática abordou um Gol Branco perto da Giovanni Gronchi ali com alguns tijolos de maconha. Eles falaram que tinham pegado na Rua da Jangada com um indivíduo tal, e bateu as características né, com a roupa dele, e depois ele confessou que era ele mesmo, que tinha distribuído pro casal. Ele usava uma camiseta cinza, se não me engano. Não me recordo se era calça ou shorts. Estava na posse dele o dinheiro, pouca quantia. Sim (o que causou a suspeita foi o comportamento do réu). Sim (o réu que indicou a localização da casa). Sim, sim (ele afirmou que o dinheiro era oriundo da venda de drogas). O casal já estava preso, né. A abordagem do casal foi antes da abordagem dele. O barraco estava fechado e a droga estava espalhada na casa inteira”.

Rafael Alberto de Souza, por sua vez, esclareceu que: “Sim (recorda-se do acusado). Eu tinha pago uma ocorrência que não tinha nada a ver, a princípio, com tráfico de drogas. Era um roubo de pessoas que tinham efetuado pela Giovanni Gronchi/Avenida José Galante e tinham se evadido para dentro da comunidade. Entramos lá e, quando a gente entrou, viu esse rapaz com uma sacola grande na mão. Na hora que ele avistou a gente, estranhamento largou ela no chão. Aí a gente efetuou, então, a abordagem dele, falou “ei rapaz, por que você soltou a sacola no chão?” aí ele falou “é droga”, aí a gente abriu e tinham alguns tijolos de maconha dentro. Depois disso, ele indicou que era bem próxima a viela onde tinha o resto da droga. A gente foi até lá e encontrou com a chave que ele próprio forneceu. Ele forneceu o endereço (do imóvel) e forneceu a chave. Lá dentro, foram encontrados vários tabletes grandes de maconha, balança de precisão industrial, balança de precisão de cozinha, marreta de borracha, alguns utensílios utilizados para separar e embalar drogas. Sim (foram encontrados rolos de fita plástica e adesiva), de tudo tinha lá, tudo que era necessário (para embalar entorpecentes), tinha cento e pouco invólucros grandes. Tinha um pacote lá com uma substância grande que a gente não sabe ainda se era xilocaína ou se era cocaína, mas eu não me lembro de ter visto o laudo. Sim (recorda-se da apreensão da substância branca). Também (essa substância foi encontrada no imóvel), junto. Ele disse que armazenava por lá e distribuía, revendia para outras pessoas, para mim ele só falou isso. Era uma casa de alvenaria, com portas, e não tinha só um tipo (de droga), tinham vários outros tipos, tinha rolo de tudo que era plástico, mas a cor não me lembro, não sei dizer (se era igual ou não a que foi apreendida em posse do acusado), mas foi ele que indicou o local, ele tinha chave, tinha tudo. Essa casa era inabitada

aparentemente. Essa ocorrência (do casal), por coincidência, nosso comando abordou um carro que tinha uma droga parecida em outro local, mas foi muito simultâneo. Eles abordaram em outro local que tinha a mesma droga que parecia isso daí, então quando nós pedimos apoio, porque ali é um local de alto risco, todo mundo chegou no apoio, viu a droga, viu a mesma característica, essas outras pessoas que tinham sido abordadas falou que tinha pego com o rapaz, que atendia por um nome que não me lembro, que era baixinho, que batia com todas as características desse rapazinho aí.”.

Como consignado, a prova produzida no contraditório é farta na demonstração da ocorrência do delito, sendo incontroversa a autoria.

Nas oportunidades em que foi interrogado, o acusado negou o cometimento do crime, mas apresentou versões contraditórias, o que demonstra que faltou com a verdade.

Ouvido em solo policial, acompanhado de sua Defensora, limitou-se a afirmar que foi preso por força de injusta perseguição policial, apenas porque estava portando um “baseado” – ou seja, um cigarro de maconha – e porque os milicianos alegaram que “sabiam quem ele era”.

No contraditório, entretanto, apresentou esclarecimentos absolutamente destoantes dos prestados na fase administrativa, justificando que de fato estava envolvido com o comércio espúrio de entorpecentes – já que seria o “olheiro” dos traficantes –, mas justificou que não era o responsável e sequer tinha conhecimento da existência dos entorpecentes no tal depósito.

Não bastasse, há inúmeras inconsistências e contradições nos esclarecimentos que prestou em Juízo.

Em um primeiro momento, declarou que os milicianos pegaram das suas vestes - bolso - as chaves que utilizaram para ingresso no imóvel. Entretanto, no decorrer do depoimento, alterou essa informação e afirmou que não trazia nenhuma chave consigo. De mais a mais, declarou a priori, que: “eu era o olheiro dessa casa”, mas novamente alterou a versão e afirmou que: “Eu era olheiro da rua, eu não cuidava da casa”, alegando que sequer tinha conhecimento da localização do imóvel.

Enfim, essas singelas negativas de autoria – bastante pueris, confusas e inconsistentes – não são merecedoras de nenhuma credibilidade e nem de longe foram comprovadas pela Defesa, como lhe competia fazer, nos termos do que prevê o artigo 156, do Código de Processo Penal.

Aliás, acatar a falaciosa fala do réu implicaria reconhecer que houve verdadeiro conluio criminoso engendrado pelos policiais militares, com o exclusivo objetivo de incriminar injustamente pessoa que sequer conheciam.

Não parece mesmo crível.

Ao contrário, os policiais militares ouvidos em Juízo, de forma bastante serena e insuspeita, deram conta da diligência que realizaram, uma vez que patrulhavam pelo local dos fatos, avistaram o acusado – que, ao notar a presença da guarnição dispensou uma sacola que continha tijolos de maconha – e, por consequência, decidiram pela abordagem. Durante a revista pessoal, localizaram uma quantia de dinheiro em espécie e um molho de chaves nas vestes dele, mais precisamente em um dos bolsos. Questionado, ele afirmou que seria de uma casa que continha mais drogas, e que era localizada no interior da viela.

Em seguida, o acusado os levou até o imóvel em questão, localizado a cerca de 500 metros do local da abordagem. Lá chegando, abriram a porta do imóvel – com as chaves apreendidas em poder do réu – e localizaram inúmeras porções de

entorpecentes, ou seja, cerca de 170 (cento e setenta) tijolos de maconha, cocaína e outros petrechos comumente utilizados no comércio espúrio de entorpecentes, como plástico-filme, balança de precisão industrial, marretas e facas.

De mais a mais, afirmaram que outra equipe da polícia militar havia detido um casal nas proximidades e que transportava tijolos de maconha em um Gol Branco, o que se deu pouco tempo antes de terem visto o acusado. Acrescentaram que referido casal lhes informou o local onde teriam pegado a droga e as características físicas do fornecedor, que coincidiam com as do acusado. E o acusado confirmou que realmente estava “no tráfico” e havia fornecido maconha para um casal: “Ele falou que a droga realmente era dele, inclusive ele havia distribuído para um casal do interior com um Gol Branco alguns tijolos de maconha, que a equipe de força tática havia abordado (...) A equipe de força tática abordou um Gol Branco perto da Giovanni Gronchi ali com alguns tijolos de maconha. Eles falaram que tinham pegado na Rua da Jangada com um indivíduo tal, e bateu as características né, com a roupa dele, e depois ele confessou que era ele mesmo, que tinha distribuído pro casal.”.

Diante de tais circunstâncias, deram voz de prisão em flagrante ao acusado e o conduziram à delegacia de polícia.

Vale consignar que os esclarecimentos apresentados pelos policiais são dignos de toda credibilidade, sobretudo não existindo demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente. Como qualquer testemunha, os policiais militares prestam compromisso de dizer a verdade, e a versão que apresentam só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não ocorre no caso em tela.

Nesse sentido: “Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas”. (TJRJ – AC – Rel Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

Quanto ao tóxico apreendido, desnecessário maiores digressões acerca de sua destinação. O desiderato de mercancia é manifesto e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para dúvidas.

A forma como as drogas estavam acondicionadas – 156 (cento e cinquenta e seis) tijolos de maconha, pesando 114,13 kg (cento e quatorze quilogramas e cento e trinta gramas); 25 (vinte e cinco) porções de maconha, pesando 557,2 g (quinhentos e cinquenta e sete gramas e dois decigramas) e 01 (uma) porção de cocaína, pesando 513,2g –, bem como as circunstâncias da prisão, afastam qualquer dúvida quanto à sua finalidade, de forma que não há que se falar em desclassificação do crime denunciado para o previsto no artigo 28 da Lei Especial.

Ademais, apenas por argumentação, nem mesmo o próprio acusado reivindicou as drogas apreendidas para consumo pessoal – o que não se cogita, em razão da excessiva quantidade, totalmente incompatível com a posse para mero consumo.

Assim não fosse, consigne-se que a situação de usuário de drogas não exclui a de traficante, uma vez que: “Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização” (TJSP – AC 9.751-3 – Rel. Gonçalves Sobrinho – RJTJSP 75/343).

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP – HC 42.229-3 – Rel. Onei Raphael – RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão dependência, inadmissível - Inteligência dos arts. 12 e 16 da Lei 6.368/76." (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

E ao contrário do que pretende a Douta Defesa, não é o caso de desclassificação do crime denunciado para a figura típica prevista no artigo 37 da Lei nº 11.343/06.

Ainda que se admita que a função do acusado no comércio espúrio em questão fosse apenas a de olheiro - o que por óbvio não é o caso, como muito bem demonstrou a prova produzida -, seria o quanto basta para a configuração do delito previsto no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. O acusado atuava na mercancia de forma intencional e consciente para promover a venda de drogas, de sorte que não se trata de mero colaborador ou informante.

Como já se decidiu: "Apelação. Crime de tráfico de drogas majorado pelo concurso com adolescente. Sentença condenatória. Recurso da defesa. (...) 2. Não é o caso de desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 37, da Lei nº 11.343/06. O informante a que alude o tipo penal corresponde ao agente que pratica uma ação acessória no grupo ou organização criminal. No caso, a atividade de "olheiro" assim como a de "segurança", tal como desenhada nos autos, é fundamental ao exercício do comércio de drogas, pois dela depende o sucesso da empreitada criminosa. 3. (...) Negado provimento ao recurso". (TJ-SP -Apelação Criminal nº 1500121-31.2019.8.26.0537, Relator (a): Laerte Marrone, 14ª Câmara de Direito Criminal, DJe em: 08/10/2019).

"Desclassificação para a conduta do art. 37 da Lei de Drogas. Inocorrência. Alegado pelo réu a função de "olheiro", de qualquer maneira deve ser condenado pelo tráfico de drogas (artigo 33, da Lei 11.343/06), já que tal atividade, de "olheiro", é diretamente ligada ao hediondo comércio, atuando a pessoa nesse sentido como coautor do delito de tráfico de drogas, porque participando da efetiva execução dele, não se confundindo com a conduta prevista no artigo 37 da Lei 11.343/06, de mero prestador de informações. Negado provimento ao apelo do réu e dado provimento ao reclamo ministerial." (TJ-SP -Apelação Criminal nº 1500583-86.2018.8.26.0548, Relator (a): Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, DJe em: 21/08/2020).

Logo, comprovado o desiderato de mercancia, incontroversa a responsabilidade do réu pelas drogas, a condenação pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é medida de rigor.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

Ao que consta, o acusado era primário à época dos fatos.

Não obstante, as circunstâncias judiciais não lhe são nada favoráveis. O artigo 42 da Lei 11.343/06, que prepondera sobre critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, determina que, na fixação das penas, deverão ser consideradas a natureza e a quantidade das substâncias, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso em apreço, como dito, o réu foi surpreendido em poder de mais de 115 quilos de droga, parte fracionada (25 porções) e parte separada em 156 tijolos de maconha, e ainda 01 porção de mais de meio quilo de cocaína, substâncias causadoras de severos danos à saúde pública, aos viciados, às famílias e a sociedade, em quantidade suficiente para abastecer milhares de usuários e diversos pontos de venda. Logo, pela intensidade do dolo que fez parte do réu, pelas circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base no dobro do mínimo legal, ou seja, em dez anos de reclusão e mil dias-multa, calculada a unidade no mínimo

legal.

Não há que se falar em confissão espontânea, porquanto a versão apresentada pelo réu não retratou a verdade real dos fatos. Com efeito, ele negou a posse dos entorpecentes e demais petrechos apreendidos, justificando que exercia apenas a função de “olheiro” no tráfico, ou seja, era o responsável por alertar os traficantes a respeito do ingresso de policiais na viela.

E nos termos do que preceitua a Súmula nº 630 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante da confissão espontânea no tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, o que não ocorreu no caso dos autos.

Incidu, no caso concreto, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, já que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19 (Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020).

Cumpr salientar, que a lei não exige nexo de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime praticado pelo agente. Basta, para o reconhecimento da agravante em questão, que o delito seja executado durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, reconhecida por meio dos decretos supramencionados, o que indica insensibilidade moral do agente e ausência de fraternidade e solidariedade social.

Destaca-se que o texto legal é expresse ao estabelecer a incidência da referida circunstância quando o crime é praticado por ocasião de calamidade pública, não exigindo nexo de causalidade.

Entretanto, referida agravante fica compensada com a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o acusado contava com menos de 21 anos de idade à época do crime.

E não estão presentes os requisitos para a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/06.

Os elementos de convicção produzidos bem demonstraram que o acusado se dedicava à atividade criminosa em questão. Conforme se verificou, ele era responsável pelo armazenamento, guarda e distribuição de mais de cem quilos de entorpecentes, de natureza diversificada, o que fazia de forma extremamente organizada e sistemática, já que dispunha de imóvel destinado exclusivamente ao armazenamento das drogas e de expressivo aparato para a prática da mercancia – facas, martelos, diversas balanças de precisão, celulares e rolos de plástico (auto de exibição e apreensão – págs. 19/20).

Ademais, não comprovou o exercício de qualquer atividade lícita, admitindo, inclusive, que estava envolvido com o comércio espúrio de entorpecentes há quase um mês. Ademais, ao que consta, havia acabado de servir tijolos de maconha para um casal, e foi surpreendido por policiais com outros tijolos da mesma droga em uma sacola, certamente aguardando pelo destinatário.

Tais circunstâncias demonstram, de forma inequívoca, que o réu fazia da mercancia seu meio de vida e não foi o crime aqui tratado fato isolado em sua vida.

Por fim, a natureza, a quantidade, a forma de armazenamento das drogas, o local destinado ao depósito das substâncias encontradas sob a guarda e responsabilidade do acusado revelaram-se incompatíveis com o tráfico esporádico, eventual.

Ora, não se confia tamanha quantidade de entorpecente a quem é incipiente no ramo.

Desta forma, a grande quantidade de droga apreendida impede a aplicação do

reduzidor, uma vez que capaz de abastecer milhares de usuários, atingindo um número considerável de pessoas e causando danos irreversíveis à saúde pública.

Nesse sentido: "PENA - Fixação - Tráfico ilícito de entorpecentes - Aplicação do reduzidor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Federal n. 11343/06 - Inviabilidade - Agente surpreendido quando trazia consigo 59 porções de maconha e 11 de cocaína - Quantidade de drogas apreendidas indicadora de que o réu faz do tráfico seu meio de vida, ou seja, de que se dedica à atividade criminosa, não sendo, portanto, merecedor da redução da reprimenda - Recurso da defesa improvido, sendo dado parcial provimento ao ministerial para elevar as penas impostas." (Apelação Criminal n. 990.09.081797-6 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery - 01.10.09 - V.U. - Voto n. 15796).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra LUIZ HENRIQUE ALVES ARAUJO, R.G. nº 54.962.312, e o condeno ao cumprimento de dez anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a mil dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO, pelo que dispõe a Lei nº 11.464/07, que alterou a redação original do artigo 2º, § 1º da Lei nº 8.072/90. Ademais, o regime fechado é o único compatível com a natureza do crime aqui tratado, considerado hediondo, especialmente no caso concreto, que revelou periculosidade do acusado, que portava para comércio inúmeras porções de maconha e cocaína, e praticava a mercancia de forma reiterada, considerando-se, ainda, o quantum de pena imposto.

Tendo em vista a gravidade do crime aqui tratado, considerado hediondo, ainda pelas razões consignadas por ocasião da fixação da pena-base, o acusado NÃO poderá recorrer em liberdade, deverá ser recomendado na prisão em que se encontra e, igualmente, não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, que não tem aplicação ao crime tratado na presente ação penal, que tem regras especiais e que são aplicadas em detrimento das gerais. Por se tratar de crime hediondo, que compromete a saúde pública, a medida não se mostra socialmente recomendável.

Pelos fundamentos acima expostos, bem como por tudo quanto produzido no contraditório, presentes os requisitos legais, MANTENHO a prisão preventiva anteriormente decretada, nos termos do que estabelece o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ademais, a medida se mostra necessária, inclusive, para assegurar o cumprimento da pena aplicada.

É certo que o réu está preso desde 19 de março passado, mas não é o caso de regime mais brando para início de cumprimento da pena (artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal - detração penal), por se tratar de matéria que deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, como determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei nº 7.210/84, com observância do que dispõe o artigo 112 e parágrafo 1º, da mesma lei.

Nesse sentido: "Por fim, inaplicável o artigo 387, parágrafo 2º, do Diploma Processual, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual da acusada, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda que de maneira obliqua, de verdadeira e inoportuna progressão" (Apelação nº 0007336-26.2011.8.26.0663. Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA).

Condeno o acusado ao pagamento das custas do processo, nos termos do que estabelece o artigo 804 do Código de Processo Penal. Eventual pleito de isenção de custas deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, momento oportuno para verificação de forma mais detalhada acerca da capacidade financeira do acusado (STJ

- 6ª Turma, REsp 1.637.275/RJ).

Nos termos dos artigos 62 e seguintes da nº Lei 11.343/06 e do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, DETERMINO a perda em favor da União da quantia em espécie apreendida em poder do acusado - R\$ 328,00 (trezentos e vinte e oito reais) - relacionada no auto de exibição e apreensão (págs. 19/20), uma vez que oriunda do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de agosto de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA